

1500638-36.2020.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... já foi preso e atualmente está preso por tráfico de drogas".

De proêmio, verifico que o caso em exame diz respeito à exata classificação do delito, ou seja, quanto ao propósito mercantil, que é o elemento subjetivo caracterizador do crime de tráfico posto que incontroversa a materialidade do delito, bem como restar evidenciado ser o réu o proprietário das drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500638-36.2020.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500638-36.2020.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2144638/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 11893040 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 1694/20/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2144638 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2144638 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1694/20/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUIZ APARECIDO LEANDRO DA SILVA LEANDRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

LUIZ APARECIDO LEANDRO DA SILVA LEANDRO, vulgo "zinho", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, na data de 16 de junho de 2020, por volta da 1h20min, na Rua João Teles de Menezes, 448, casa 1, Jardim Planalto,

nesta cidade e Comarca, transportou e trouxe consigo, para entrega e consumo de terceiros, 80 (oitenta) porções de cocaína, embaladas em plásticos fechados por nó, com peso bruto de 39,1g (trinta e nove gramas e dez centigramas), substância esta causadora de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 16, constatadas como tal pelo laudo pericial preliminar a fls. 31/34 e confirmadas pelo exame químico toxicológico a fls. 212/214, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/219. Em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 108/110). Mandado de prisão cumprido a fls. 172/175. Por liminar concedida nos autos do Habeas Corpus nº 2135703-68.2020.8.26.0000 houve a concessão da liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (fls. 155/159). Alvará de soltura cumprido a fls. 166/169. Devidamente notificado (fls. 240), o réu apresentou defesa preliminar a fls. 237/238. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2020, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 241/242). Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu interrogado (fls. 269/270, 382/383 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, bem como pelo agravamento da pena base ante a quantidade de droga apreendida, pela fixação do regime inicial fechado e pela impossibilidade de recorrer em liberdade (fls. 386/390). A douta Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição e desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei de Drogas. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pela aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 393/402).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto promovia o comércio ilícito de drogas nesta cidade. Na ocasião fática, durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de uso e venda de drogas, uma equipe da Polícia Militar encontrou um veículo ocupado por duas pessoas estacionado em frente a uma residência e os policiais decidiram abordar seu condutor, o acusado. Mesmo recebendo o sinal da viatura policial ele saiu com o veículo e dispensou uma sacola plástica pelo lado do passageiro, arremessando-a para fora do carro, o que chamou a atenção dos policiais, que conseguiram realizar a abordagem. Durante revista pessoal o acusado demonstrou inconformismo e nada de ilícito foi encontrado com ele. Eles, então, retornaram ao local em que LUIZ havia dispensado a sacola e a encontraram, revelando 80 (oitenta) porções de cocaína, devidamente fracionadas e embaladas para venda a terceiros. É certo que a apreensão da droga, as declarações dos policiais militares e, sobretudo, as circunstâncias fáticas da prisão, evidenciam que o denunciado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas".

Pois bem, examinada a questão à luz da prova produzida, é forçoso reconhecer que a denúncia procede parcialmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência a fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fls. 16, fotografias a fls. 19/21, laudo de constatação provisória a fls. 31/34, laudo de exame toxicológico a fls. 212/214, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou incontestada e recai sobre o réu. A testemunha de acusação Valdinei Ribeiro Pereira, policial militar, em juízo, contou "que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, eis que ali é conhecido no meio policial por ser ponto de tráfico de drogas. Disse que o réu estava em frente a casa de dois traficantes e que não obedeceu às ordens de parada dos policiais, jogando uma sacola pela janela do passageiro. Disse que, em busca pessoal, o réu resistiu, tendo que algemá-lo e que o passageiro Ronaldo não demonstrou nervosismo. Falou que foi realizada busca pessoal no carro e nos

ocupantes do mesmo, porém nada de ilícito foi encontrado. Falou que, após estar contido, foi até o local onde a sacola foi arremessada e acabou sendo localizada 80 porções de cocaína devidamente embaladas para venda. Falou que Ronaldo estava de passageiro do réu e que nada de ilícito foi encontrado com ele. Afirmou não ter dúvidas de que foi o réu quem arremessou a sacola de drogas pela janela do passageiro, pois, embora fosse noite, a rua estava bem iluminada e os vidros do carro estavam abertos, além da viatura policial estar próxima do carro do réu". A testemunha de acusação Alessandro Batista da Silva, policial militar, judicialmente, corroborou a versão dada por seu colega de farda. Acrescentou "que o réu apresentou resistência às ordens policiais, precisando ser algemado para ser realizada a abordagem. A respeito do local dos fatos, afirmou ser sabido do meio policial de que é a casa dos traficantes de drogas "Faísca" e "Fumaça". Informou, também, que o passageiro do veículo, Ronaldo, confirmou que a droga era do réu. Disse que não possui dúvidas de que foi o réu quem jogou a sacola com entorpecentes pela janela do passageiro, sendo possível o reconhecimento e diferenciação dos mesmos pelas vestimentas e diferenças na aparência física deles. Afirmou, também, que Ronaldo já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e que foi seu companheiro de farda, Ribeiro, que voltou e localizou a sacola com os entorpecentes".

A testemunha de defesa Paulo César Ramos, sob o crivo do contraditório, declarou "que nada sabe sobre os fatos, uma vez que não estava com o réu na ocasião. Disse que no dia do ocorrido estava bebendo em um bar, denominado "bar do Garcia", onde estavam Luiz e Ronaldo e que ambos saíram juntos do bar no carro de Luiz. Falou que não sabe onde eles foram e que conhece o réu do bairro e ele sempre foi trabalhador e honesto".

O réu Luiz Aparecido, em seu interrogatório judicial, disse "que já foi processado por receptação, possui o apelido de "Zinho" e na data dos fatos estava bebendo com o colega Paulo no bar do Garcia, próximo ao local dos fatos. Ao chegar ao local, encontrou Ronaldo, que ofereceu cocaína para eles e foram usar na casa do "faísca". Ao chegar em casa, "faísca" e "fumaça" estavam dormindo, por isso voltou para seu carro, onde já estava Ronaldo com uma sacola contendo cocaína para escolher, e pretendia pegar uma ou duas porções. No momento em que escolhia, contudo, passou uma viatura da polícia na rua e ficou apavorado. Bateu a mão na sacola e não sabe informar se ela caiu fora ou dentro do carro, já que estava bastante alcoolizado. Afirmou, também, que a droga era de Ronaldo e não sua. Ronaldo já foi preso e atualmente está preso por tráfico de drogas".

De proêmio, verifico que o caso em exame diz respeito à exata classificação do delito, ou seja, quanto ao propósito mercantil, que é o elemento subjetivo caracterizador do crime de tráfico posto que incontroversa a materialidade do delito, bem como restar evidenciado ser o réu o proprietário das drogas apreendidas, como por ele admitido.

Vê-se da prova amealhada que não houve flagrante quanto a nenhum ato de venda, mas tão somente a apreensão da droga. A quantidade de entorpecente encontrada e a forma como se encontrava embalada não caracteriza, por si só, o crime de tráfico, que exigiria, para esse fim, a comprovação de atos inequívocos do comércio ilícito. Além disso, cabe destacar que, no dia dos fatos nenhum dos policiais presenciou qualquer contato do réu com eventual usuário e adquirente, de modo a conferir respaldo à imputação por tráfico de drogas. Em consequência, inviável a condenação pelo delito mais grave. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova, para tanto, deve ser das mais seguras. É certo que, no caso dos autos, a quantidade de entorpecentes apreendidos, conquanto se mostre expressiva (80 porções de cocaína), leva à presunção da prática do tráfico. Todavia, a presunção não é elemento suficiente para justificar uma condenação, mormente em casos como o dos autos, onde negada a atividade pelo réu e não há outro elemento, objetivo e idôneo, a indicar o tráfico. Não se trata, à evidência, de duvidar ou questionar o depoimento de policiais que, no cumprimento de sua missão, atuam na repressão penal, posto que tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Trata-se, isso sim, de exigir a correta formação de culpa, em atenção ao princípio

constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado. Dessarte, não se pode descartar a hipótese de que a droga se destinasse ao consumo próprio. Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, até porque não trazidos aos autos elementos outros, tais como expressiva quantidade de droga, manuscritos contábeis, dentre outros, que indicassem o comércio ilícito, valendo ressaltar que a forma como acondicionado o entorpecente tanto pode indicar o tráfico como a aquisição para uso próprio. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11343/2006; reconhecimento da figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. - Pleito absolutório inatendível. Comprovadas autoria e materialidade. Cabível a desclassificação para o delito do art. 28. Réu admitiu a posse para consumo próprio. Circunstâncias não demonstram que a destinação das drogas era a comercialização. Policiais não presenciaram atos de mercancia. Pena. Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. - Recurso provido, em parte, para desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, no termos do v. Acórdão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado." (Apelação Criminal nº 1500249-08.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator(a): Osni Pereira, data de julgamento e publicação: 29/01/2021) (destaquei)

...
"TRÁFICO DE DROGAS -Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio -Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio -Admissibilidade -Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 - Recurso improvido - (voto n. 43702) (Apelação Criminal nº 1500582-14.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, 16ª Camara de Direito Criminal, Relator(a): Newton Neves,data de julgamento e publicação: 02/02/2021) (destaquei)

Assim, embora apontados indícios de que o réu se dedique ao comércio ilegal de drogas, certo é que a prova da finalidade mercantil do entorpecente é frágil e meramente indiciária, não restando cabalmente demonstrado que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância.

Doutra parte, cumpre consignar que, como se sabe, é do balanço do conjunto dos critérios valorativos que se conceitua a diferenciação entre traficante e usuário. E ninguém pode ser condenado por presunção, visto que o reconhecimento da traficância exige prova concludente. Em suma: o conjunto probatório se mostra frágil e duvidoso no tocante ao tráfico, eis que não se comprovou com a certeza indeclinável, fosse o acusado mercador de drogas.

Diante da situação concreta aqui verificada, e não havendo outros indicativos de prova efetiva quanto ao crime de tráfico, o que faz pairar nos autos a dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve prevalecer a desclassificação para o crime de posse para uso próprio. Logo, de rigor a condenação, mas como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu LUIZ APARECIDO LEANDRO DA SILVA LEANDRO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Atento a finalidade preventiva e repressiva do mencionado artigo, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 321/332) a medida mais adequada é a inserida no inciso II, qual seja, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses. Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Avare, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA